

Les centrales d'achats : avantages et inconvénients

Si la mutualisation des achats est un outil performant au service de la rationalisation de l'achat public, ainsi qu'en témoignent les nombreux avantages qui en découlent, un tour d'horizon des avantages et inconvénients spécifiques aux centrales d'achats permettra utilement aux acheteurs d'évaluer l'opportunité d'y avoir recours, au détriment d'autres formes de mutualisation, et plus particulièrement des groupements de commandes.

Pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, fournitures et services, les acheteurs publics ont la possibilité de lancer des procédures de marchés publics de façon séparée, ou de « rationaliser l'achat public »^[1], en ayant recours à une centrale d'achats, ou en se regroupant avec d'autres entités. Dans ces deux dernières hypothèses, on parle alors de mutualisation des achats.

En application du Code de la commande publique, la mutualisation des achats peut prendre trois formes différentes : les centrales d'achat, les groupements de commandes et les entités communes transnationales^[2].

Cette mutualisation est source de nombreux avantages pour les personnes publiques, parmi lesquels on doit d'abord relever les économies d'échelle qui sont réalisées et donc les prix plus compétitifs qui sont obtenus^[3]. En effet, l'agrégation des besoins des différentes structures impliquées engendre un volume d'achat supérieur à celui d'un acheteur isolé.

La mutualisation des besoins permet également de réduire les coûts relatifs à la procédure de passation des marchés publics^[4], dès lors qu'une seule équipe d'acheteurs est mobilisée pour la prise en charge des commandes de plusieurs structures^[5].

C'est aussi en termes de gain de temps et d'apport qualitatif que l'on peut apprécier l'achat groupé, puisque celui-ci « permet de se décharger des missions d'achat public

Auteur

Marion Terraux

Candice Méric

Avocats à la Cour
SCP Seban & Associés

Mots clés

Centrale d'achats • Groupement de commandes • Personnalité morale

[1] A. Taillefait, « Coordination, Groupement de commandes et centrale d'achats », p. 1, *Jurisclasser Contrats et Marchés Publics*, Fascicule 50.

[2] Code de la commande publique, art. L. 2113-2 et s.

[3] O. Laffitte, « Centrales d'achats : un levier incontournable d'efficacité de la commande publique », *Contrats Publics – Le Moniteur*, n° 149, décembre 2014.

[4] Fiche DAJ, « La mutualisation des achats », p. 1.

[5] Groupement de commandes et centrale d'achat, Dalloz (dictionnaire permanent).

sur des services aux compétences pointues »⁽⁶⁾, soit des services qui sont à même de sécuriser des produits et des prestations de qualité⁽⁷⁾. De tels avantages sont d'autant plus probants que les collectivités sont de petite taille, et dépourvues de services achats structurés et du personnel nécessaire⁽⁸⁾.

Les acheteurs ne sont pas les seuls à bénéficier des avantages de l'achat groupé. Les prestataires aussi sont gagnants dans la mesure où les centrales d'achats leur permettent d'intervenir auprès de multiples acheteurs⁽⁹⁾.

Toutefois, une fois que les acheteurs ont décidé de se regrouper, deux outils principaux s'offrent à eux : la centrale d'achat et le groupement de commande.

Afin d'orienter les acheteurs dans le choix de la forme de mutualisation la plus adéquate pour leur projet, on analysera les avantages et les inconvénients que présente le recours à une centrale d'achats, particulièrement en regard des groupements de commande, en mettant l'accent sur les considérations susceptibles d'intéresser les acheteurs en termes de constitution des centrales d'achats et de mise en œuvre de celles-ci⁽¹⁰⁾.

Constitution des centrales d'achats

Souplesse de création et liberté de choix de la forme des centrales d'achat

Les centrales d'achats sont des acheteurs qui ont « pour objet d'exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l'une au moins des activités d'achat centralisées définies [par le Code de la commande publique] »⁽¹¹⁾.

L'État, les collectivités locales ou les établissements publics, en leur qualité d'acheteurs publics - pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice - peuvent recevoir la qualification de centrale d'achat dès lors qu'ils exercent les activités qui seront précisées ci-après, et sous réserve de respecter « les limites de [leurs] statuts et de [leur] compétence »⁽¹²⁾.

La possibilité de créer une structure ad hoc dédiée à la centralisation des achats qui, soit de droit public ou de droit privé, atteste la grande marge de manœuvre qui est laissée, s'agissant du choix du statut juridique de la centrale d'achat, et en l'absence de prescription du Code de

la commande publique sur ce point, aux acheteurs publics qui en sont à l'initiative.

Les centrales d'achats peuvent ainsi prendre la forme d'un établissement public, sous réserve de ne pas porter atteinte au principe de spécialité qui lui est applicable (l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP)⁽¹³⁾ et l'Économat des Armées⁽¹⁴⁾ en sont les plus célèbres illustrations), d'un Groupement d'Intérêt Public (comme le Réseau des acheteurs hospitaliers de France (Resash-Idf) ou encore Approlys Centr'achats), d'une association (telle la centrale d'achat du transport public ou CATP), ou d'un Groupement d'Intérêt Economique.

Cependant, cette grande liberté de choix souffre certaines limites. Le choix de l'association a ainsi été vivement déconseillé à plusieurs reprises, s'agissant des centrales locales d'achat.

Un rapport datant d'avril 2016 et co-écrit par l'inspection générale des finances (IGF) et l'inspection générale de l'administration (IGA) évoque « le risque juridique de gestion de fait [...], si l'association est considérée comme 'transparente'⁽¹⁵⁾ », qu'il convient de mettre en regard de la « sécurité juridique contre le risque de qualification de gestion de fait pour les collectivités fondatrices »⁽¹⁶⁾ que représente le choix du Groupement d'Intérêt Public pour la création de la centrale locale d'achats sous cette forme, en dépit de la complexité de sa mise en œuvre.

Un groupement de commandes est pour sa part nécessairement structuré à travers l'établissement d'une convention constitutive⁽¹⁷⁾, ce qui est nécessairement plus simple et plus rapide qu'une centrale d'achats.

Composition organique stricte des centrales d'achats

La centrale d'achat agissant au nom et pour le compte des seuls acheteurs soumis au Code de la commande publique⁽¹⁸⁾, cela signifie qu'elle ne peut en aucun cas inter-

(6) Groupement de commandes et centrale d'achat, Dalloz (dictionnaire permanent).

(7) A. Taillefait, « Coordination, Groupement de commandes et centrale d'achats », p. 5, *Jurisclasseur Contrats et Marchés Publics*, Fascicule 50.

(8) D. Maslanka, « Forces et faiblesse des groupements de commandes », *Contrats Publics - Le Moniteur*, n° 149, décembre 2014.

(9) Fiche DAJ, La mutualisation des achats, p. 1.

(10) On notera que les centrales d'achats relatives aux marchés de défense ou de sécurité ne font partie du champ de notre étude.

(11) Code de la commande publique, art. L. 2113-2.

(12) Fiche DAJ, La mutualisation des achats, p. 2. CAA Marseille 5 juillet 2004, Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, req. n° 04MA01109.

(13) Décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP).

(14) Code de la défense, art. R. 3421-2.

(15) Rapport de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'administration, *Revue de dépenses relatives à la fonction achats des collectivités territoriales*, avril 2016, Annexe IV, p. 50 : « Lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente » (CE 21 mars 2007, req. n° 281796 ; Cass. crim. 7 novembre 2012, n° 11-82.961). A contrario, une association n'est pas transparente lorsqu'elle dispose d'une « autonomie de fait suffisante à l'égard de la collectivité qui l'a suscitée et qui contribue à la financer » (rapport du Conseil d'État sur les associations, 2000).

(16) Rapport de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'administration, *Revue de dépenses relatives à la fonction achats des collectivités territoriales*, avril 2016, Annexe IV, p. 50.

(17) Code de la commande publique, art. L. 2113-7.

(18) Aux termes des articles L. 1210-1 et s. du Code de la commande publique, il s'agit des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices.

venir pour le compte de personnes morales de droit privé qui n'ont pas, pour leur part, la qualité d'acheteur.

En regard de la composition organique stricte d'une centrale d'achat, on comparera celle, plus souple, des groupements de commandes. Ceux-ci peuvent réunir, aux côtés d'un ou des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, « une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs »^[19], à la condition cependant que soient appliquées, par chacun des membres du groupement ainsi formé, et pour les achats réalisés dans ce cadre, des règles relatives aux marchés public du Code de la commande publique^[20]. Ainsi, l'opportunité de réunir côte à côte acheteurs publics et personnes morales de droit privé dépourvus de ce statut ne manquera pas d'orienter l'acheteur à l'initiative du projet vers l'une ou l'autre forme de mutualisation des achats.

L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a introduit des dispositions somme toute assez similaires, s'agissant de la mutualisation des achats au-delà des frontières françaises. L'acheteur peut ainsi opter pour une centrale d'achat située dans un autre État membre de l'Union européenne, ou constituer un groupement de commandes avec des acheteurs d'autres États membres de l'Union européenne, sous réserve que, dans l'un et l'autre cas, ce choix n'ait pas été motivé par l'objectif d'échapper à l'ordre public. Dans ces deux hypothèses, l'application du droit français est en effet soit écartée d'office - le choix de la centrale d'achats située dans un autre État membre de l'Union européenne entraînant l'application au marché public de la loi de l'État membre de la centrale d'achat sollicitée^[21] - soit laissée à l'appréciation des acheteurs membres du groupement de commandes puisqu'ils peuvent notamment s'entendre sur le droit applicable au marché parmi les droits de ces différents États^[22].

Personnalité morale de la centrale d'achats

Le choix de recourir à une structure dotée de la personnalité morale, comme c'est le cas de la centrale d'achats, au contraire d'un groupement de commandes, qui s'apparente à un simple « mode d'organisation centralisée des achats »^[23], étant de ce fait dépourvu de personnalité juridique^[24], est également à prendre en considération par l'acheteur.

L'absence de personnalité juridique d'un groupement de commande emporte comme conséquences, d'une part, l'impossibilité pour le groupement de contracter et d'agir en justice et, d'autre part, l'impossibilité d'engager sa responsabilité. La Direction des affaires juridiques du mi-

nistère de l'Économie et des Finances a précisé que « si seul le coordonnateur désigné par la convention constitutive du groupement est susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait des irrégularités de la procédure de passation^[25], l'ensemble des membres est solidairement responsable lorsque la passation et l'exécution d'un marché public sont menées conjointement dans leur intégralité au nom et pour le compte de tous les acheteurs concernés^[26] »^[27].

Mise en œuvre des centrales d'achats

Les centrales d'achats ont des missions plus larges que les groupements de commande

Le choix de passer par une centrale d'achats, plutôt que par un groupement de commandes, peut être motivé par la variété de missions que peut prendre à sa charge cette structure de mutualisation des achats.

Ainsi, une centrale d'achats peut exercer une mission d'intermédiaire contractuel. Dans ce cadre, elle se charge de la passation de marchés publics répondant aux besoins d'autres acheteurs pour le compte de ces derniers.

Elle peut également exercer une mission de grossiste. Dans ce cas, elle procède à l'acquisition de fournitures et biens qu'elle stocke puis cède aux acheteurs.

De plus, en complément des activités que l'on qualifiera de « principales », que peut exercer une centrale d'achats, la réforme des marchés publics de 2015 a aménagé la possibilité de conduire des activités d'achats dites « auxiliaires » consistant à fournir une assistance à la passation des marchés publics, que l'article L. 2113-3 du Code de la commande publique énumère de la façon suivante, sans que cette liste ne soit exhaustive :

« 1° Mise à disposition d'infrastructures techniques pour la conclusion des marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

2° Conseil sur le choix, l'organisation et le déroulement des procédures de passation de marchés ;

3° Préparation et gestion des procédures de passation de marchés au nom de l'acheteur concerné et pour son compte ».

Les membres d'un groupement de commandes peuvent décider, à travers la convention constitutive du groupement, de « confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché au nom et pour le compte des autres membres »^[28].

[19] Code de la commande publique, art. L. 2113-6.

[20] Code de la commande publique, art. L. 2113-6.

[21] Code de la commande publique, art. L. 2113-5.

[22] Code de la commande publique, art. L. 2113-5 et L. 2113-8.

[23] Groupement de commandes et centrale d'achat, Dalloz (dictionnaire permanent).

[24] CAA Lyon 10 juillet 1992, Société Béthenod, req. n° 91LY00119. Voir également le *Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics*, 26 septembre 2014, art. 6.2.

[25] CAA Bordeaux 12 juillet 2012, Société Optima, req. n° 11BX01620.

[26] Code de la commande publique, art. L. 2113-7.

[27] Fiche DAJ, La mutualisation des achats, p. 7.

[28] Code de la commande publique, art. L. 2113-7.

Absence d'obligation pour les centrales d'achats de satisfaire un besoin propre

S'agissant d'une personne morale en charge de procéder à la passation de marchés publics pour le compte d'autres acheteurs, une centrale d'achats n'a pas à satisfaire un besoin propre lorsqu'elle passe un marché public.

Cet avantage contraste avec l'obligation faite à chaque membre d'un groupement de commandes d'être intéressé par la conclusion du ou des marchés qui seront passés dans le cadre du groupement. Une nuance significative mérite cependant d'être apportée à cette obligation, dans le cas de figure spécifique des EPCI à fiscalité propre.

L'article 65 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a introduit la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre de passer et exécuter des marchés publics pour le compte de leurs communes membres réunies en groupement de commande. Le texte précisant que le groupement de commandes doit être constitué entre des communes membres ou entre celles-ci et l'EPCI, deux conséquences doivent en être tirées :

- impossibilité pour un EPCI de passer ou d'exécuter des marchés publics pour une seule commune membre ou pour des communes non membres
- possibilité pour l'EPCI de mener la passation et l'exécution de marchés ne répondant pas à ses besoins propres, dès lors qu'il n'est pas tenu de participer au groupement de commande, et cela en dérogation aux règles prévues par les articles L. 2113-6 et suivants du Code de la commande publique.

Forme de mutualisation choisie et modalités de passation

Si centrales d'achats et groupements de commandes sont fondés sur l'idée d'une agrégation des besoins des acheteurs ou entités concernés, le choix entre ces deux modalités de mutualisation des achats n'est pas sans conséquence sur les modalités de passation.

Traditionnellement, la participation d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local à un groupement de commandes déclenchait l'institution obligatoire d'une commission d'appel d'offres, source de lourdeur procédurale, et a pu apparaître comme « un frein au développement de la mutualisation des achats »^[29]. Sous l'impulsion de la réforme de 2015, il est désormais prévu de limiter cette obligation au cas où le groupement de commandes « est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ou qu'un office public de l'habitat »^[30].

La diversité des membres d'un groupement de commandes est par ailleurs source de complexité, s'agissant des règles de passation applicables, dès lors que ses

membres sont susceptibles d'obéir à des régimes différents.

Le groupement de commandes incluant une personne morale non soumise au Code de la commande publique se voit ainsi dans l'obligation d'appliquer les règles du Code précité à l'ensemble de ses membres, pour les achats réalisés dans le cadre de ce groupement^[31].

Lorsque le groupement est composé d'acheteurs tous soumis au Code de la commande publique, ce sont les règles les plus strictes de la commande publique qui doivent être mises en œuvre^[32]. Composé d'entités adjudicatrices et de pouvoirs adjudicateurs, un groupement de commandes appliquera obligatoirement les règles de passation encadrant les pouvoirs adjudicateurs, plus strictes que les règles de passation relatives aux entités adjudicatrices^[33].

Pour sa part, l'acheteur qui a recours à une centrale agissant comme grossiste doit s'assurer que les marchés sont passés par celle-ci dans les conditions que l'acheteur aurait dû respecter s'il avait lui-même passé le marché en question^[34].

Cela signifie qu'un pouvoir adjudicateur dont le besoin à satisfaire ne relève pas de l'activité d'entité adjudicatrice d'une centrale d'achat ne saurait faire appel aux services de celle-ci, qui aurait en effet procédé à la passation d'un tel marché conformément aux règles de passation applicables aux entités adjudicatrices^[35]. Il est en revanche loisible à une entité adjudicatrice de recourir aux services d'une centrale d'achats qui aurait pour sa part passé le marché public selon les règles de passation relatives aux pouvoirs adjudicateurs, puisque celles-ci sont plus strictes que les premières^[36].

Conclusion

Les avantages que l'on prête traditionnellement à la mutualisation des achats publics – au premier rang desquels économies d'échelle et prix plus compétitifs sont les plus souvent cités – ont tendance à venir oblitérer les nuances réelles qui existent entre les différentes modalités de mutualisation mises au service des acheteurs. Le choix raisonné de la formule adéquate de mutualisation, à l'issue d'une véritable analyse en termes de coûts/avantages des modalités de mutualisation possibles, nous semble pourtant de nature à sécuriser les projets des acheteurs.

[29] Fiche DAJ, La mutualisation des achats, p. 7.

[30] CGCT, art. L. 1414-3.

[31] Code de la commande publique, art. L. 2113-6.

[32] Fiche DAJ, La mutualisation des achats, p. 8.

[33] Fiche DAJ, La mutualisation des achats, p. 8.

[34] Fiche DAJ, La mutualisation des achats, p. 3.

[35] Fiche DAJ, La mutualisation des achats, p. 3.

[36] Fiche DAJ, La mutualisation des achats, p. 3.